

1500524-77.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2096338/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 17231512 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 1788/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2096338 - DEL.SEC.TAUBATE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500524-77.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500524-77.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2096338/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 17231512 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 1788/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2096338 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2096338/2021 - DEL.SEC.TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FABIANO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

LUIZ FABIANO DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 13, e MILENA APARECIDA DE SOUZA, qualificada às fls. 14, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, sob a acusação de que, na madrugada de 09 de abril do ano de 2021, por volta das 03h15m, no interior de imóvel localizado na Avenida Vila Velha, n.º 1164, Bairro Parque Ipanema, nesta cidade e comarca, agindo em concurso tanto na ideação como na execução, comungando do mesmo propósito ilícito, guardavam consigo, para o fito de entregar a consumo de terceiros, mediante comércio, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, vinte e um gramas e quarenta e seis centigramas (21,46g), aproximadamente, da droga cocaína e vinte e sete gramas e trinta e nove centigramas (27,39g) do entorpecente Cannabis Sativa L (maconha), determinantes de dependência física e psíquica, consoante testificam o auto de constatação acostado nos autos e o laudo de exame químico-toxicológico. Versa a denúncia que se encontrava a cocaína parte na sua forma pura e natural (pó branco de granulometria fina) e parte compactada (pedras de crack), estando acondicionada em vinte e cinco (25) unidades contendo dez gramas e vinte e seis centigramas (10,26g) da substância ilícita na sua forma natural

(microtubos/ependorfs) e em noventa e sete (97) invólucros contendo onze gramas e vinte centigramas (11,2g) do mesmo produto malsinado no formato de pedras de crack. A maconha estava distribuída, na quantidade supramencionada, em vinte e oito (28) trouxinhas. Todas as embalagens divididas, repartidas e preparadas como porções individuais para a venda no varejo.

É da inicial que as drogas se destinavam à mercancia ilícita, conforme se depreende de sua quantidade e forma de apresentação, sendo apreendidas por ocasião de diligência policial realizada no local, guardadas, de comum acordo entre os réus, conhecendo ambos o lugar de ocultação dos narcóticos, em dois pacotes depositados no espaço existente entre a cama e a parede do dormitório dos réus na referida moradia.

A prisão em flagrante dos réus foi homologada e foi concedida a liberdade provisória para ambos (fls. 78/82 e 106/109).

Após o oferecimento da denúncia (fls. 95/96), a ré MILENA foi devidamente notificada (fls. 117/118), sendo que o réu Luiz não foi encontrado para notificação pessoal (fls. 119). Os réus apresentaram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (MILENA às fls. 135; e LUIZ às fls. 142/147, após nomeação de fls. 137).

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2021 (fls. 148/149) e os réus foram pessoalmente citados (MILENA às fls. 203/204; e LUIZ às fls. 220).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e os réus foram interrogados.

Em sede de memorial escrito, o Ministério Público, entendendo provados os fatos imputados na denúncia, requereu a condenação nos termos da exordial acusatória, sustentando que as drogas se encontravam no cômodo em que os réus estavam e se destinavam à mercancia ilícita. Na dosimetria penal, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo para Luiz em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis; na segunda fase, requereu agravação da pena a ambos os réus devido à reincidência; na terceira fase, postulou pelo não reconhecimento do privilégio. Requereu regime fechado para cumprimento da regência prisional.

Já a Defesa requereu, em memorial escrito, o reconhecimento da nulidade em razão de violação a domicílio, pois a entrada não teria sido franqueada pelo morador, bem como pela realização da prisão em flagrante por guardas civis municipais. No mérito, requereu a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, por não restar comprovada a intenção de comércio.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que os réus cometeram o delito que lhes imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/40), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo exame de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 07/10), pelo exame de lesão corporal realizado nos réus, que não constou lesões corporais de interesse médico-legal (Luiz às fls. 27; e Milena às fls. 28), pelo comprovante de depósito judicial (fls. 113), pelo exame químico-toxicológico, que constatou a presença das substâncias cocaína e Tetrahidrocannabinol (THC) nos materiais apreendidos (fls. 114/116 e 123/125) e, ainda, por toda prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O réu Luiz, ouvido em solo policial (fls. 13), declarou que “estava no local dos fatos, um imóvel abandonado, com várias pessoas usando entorpecentes (pedra de crack, e cocaína), sendo que o imóvel está abandonado e aberto, facilitando a entrada de pessoas que fazem uso de entorpecentes; Que na data de hoje, estava no interior do imóvel em um dos cômodos, onde havia mais pessoa, e com a chegada da viatura da GCM, todos que ali estavam correram e fugiram, sendo que foi detido pela guarda municipal; Afirma que o dinheiro encontrado em seu poder, a quantia de R\$40,00 em dinheiro lhe pertence, que adquiriu com o seu trabalho; Com relação aos entorpecentes encontrados no local, nega ser seu, e que apenas faz uso de pedra de

crack e cocaína, desconhecendo de quem poderiam ser os entorpecentes encontrados no imóvel" (sic).

O réu não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo o réu Luiz Fabiano disse que tem 40 anos, é ajudante geral. Já foi processado por furto, roubo e tráfico de drogas. É usuário de crack. Quando aconteceu já estava fora de casa, ficou em situação de rua, vigia carro, pede em faróis, não estava mais roubando. Nesse dia conseguiu um dinheiro vigiando carro, passou em um bairro, perto da casa de Daniel e comprou pedras de crack. Encontrou com ele, é usuário também. Disse que não tinha onde fumar. Ele disse que podia entrar, que já tinha uma pessoa ali fumando com ele. Entrou, usou suas pedras com ele e Milena. Não aguentava mais, acabaram as drogas. Deitaram para dormir. Ali era muito entra e sai, ela disse que podia deitar ao lado dela, com todo o respeito. Não levantou em momento algum. Ia sair no outro dia. Não tinha droga nenhuma. Comprou 4 pedras e já tinha usado as pedras. Estava usando todos os dias. Depois disso optou por parar e descansar um pouco. Já esteve lá algumas vezes. Não estava morando lá. Ia para usar sua droga. Não gosta de usar no meio da população. Sabe que ele mora sozinho e também é usuário. Tinha uns rapazes na frente da casa, um pouco para o lado, mas não pode afirmar que estavam vendendo droga, porque não viu. Dentro da casa apenas Milena. Acordou com os policiais com a lanterna na sua casa. Falou que não tinha droga. Procuraram e depois de um tempo acharam essas drogas, dizendo que eram suas. Mandaram a Milena dizer que era dele. Conheceu Milena lá. Usaram droga juntos naquela noite. Daniel foi para a delegacia com eles, prestou depoimento também e foi liberado.

A ré Milena, ouvida em solo policial (fls. 14), disse que "é usuária de entorpecentes (pedra de crack e cocaína), sendo que com frequência está no imóvel fazendo uso de pedra de crack com outras pessoas; Que na data de hoje, estava no imóvel dormindo, onde haviam várias pessoas fazendo uso de entorpecentes, quando guardas municipais chegaram, e várias pessoas que estavam no imóvel correram e fugiram, pulando um muro existente no local, mais foi detida pela guarda e na revista foi encontrado em seu poder, a quantia de R\$20,00 em dinheiro que alega ser adquirido com o seu trabalho fazendo bicos; Com relação aos entorpecentes encontrados no imóvel pelos guardas municipais, desconhece a procedência, nega ser seu, sendo que apenas é usuária de drogas" (sic).

A ré não foi ouvida em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo a ré Milena disse que tem 40 anos, faz faxina, já foi processada por roubo, era usuária de pedra de crack. Só quando eles mostraram a droga lá fora teve ciência, eles disseram que acharam na casa. Fazia três dias que estava usando drogas, dormiu. Estava dormindo quando chegaram. Não sabe onde eles acharam a droga. Estava dormindo em um quarto. Fabiano também dormia nesse quarto. Estavam apenas os três. Daniel estava em outro cômodo, separado por um sofá. Bebia com Daniel, chegava alguém, punha droga para usarem e eles usavam. Estava na casa há três dias. Fabiano tinha chegado há um dia. Ele levou droga para usarem, era crack. Não sabe se usaram toda a droga que ele levou. Começou a passar mal e dormiu. Quando foi dormir tinha uns três meninos na frente do portão. Não sabe o que faziam lá. Não ficava lá para não ser abordada. Eles entravam, davam as coisas para Daniel comer, bebida e saíam. Daniel é usuário também. Todo mundo que chega lá usa droga, leva droga para ele.

As testemunhas Márcio e Mauro, Guardas Municipais, ouvidos em solo policial (fls. 11 e 12), relataram que "na madrugada de hoje se encontrava de serviço, juntamente com o GCM Mauro, e após passarem próximo à Creche municipal Miguel Ribas Branco, no Pq. Ipanema, quando notaram que numa esquina da Av. Vila Velha, o indiciado aqui presente, identificado como sendo Luiz Fabiano Da Silva, saiu correndo ao avistar a viatura em que estavam e adentrou a um imóvel localizado no numeral 1164, da mencionada avenida - tratando de imóvel onde não há cerca ou portão - sendo que foram atrás dele e o abordaram já no interior da casa, notando que o indiciado havia se deitado num colchão e se encontrava na companhia da indiciada Milena Aparecida De Souza; através de vistoria no quarto em que eles estavam foi

encontrado entre a cama e a parede dois pacotes contendo drogas, que totalizaram 25 pinos com cocaína, 28 trouxinhas de maconha e 97 pedras de crack; com o auxílio da guarda municipal Suzan, procederam buscas nos indiciados, sendo encontrado com Luiz Fabiano a quantia de cinquenta e nove reais e, com Milena, cento e vinte reais - cuja origem não souberam informar; diante dos fatos, deu voz de prisão em flagrante aos indiciados, conduzindo-os até este Plantão Policial, para as providências devidas" (sic).

Em juízo o guarda municipal Márcio disse que a noite foram atender uma violação de alarme em uma creche próxima. Um indivíduo estava perto da creche e correu ao vê-los. Correu para essa residência, que não tinha muro, porta, era só uma estrutura de parede. No quarto fez a abordagem. Tinha um mulher também no portão. Chamaram uma equipe feminina. Acharam o dinheiro e a droga. Só estavam os dois naquele cômodo. Tinha um senhor aparentemente embriagado em outro cômodo. Depois souberam que ele era o proprietário do imóvel, Sr. Daniel, foi qualificado. Era o cômodo em que o casal ficava. O casal disse que era usuário. Disseram que estavam ali para consumir a droga. Eram 95 pedras de crack, 30 pinos e 30 papélotes de maconha, aproximadamente. Todas embaladas para a venda. Era um colchão de solteiro, no chão. Ele pulou no cantinho da cama, entre ela e a parede. Ela estava deitada no colchão. O colchão estava encostado na parede e a droga estava entre o colchão e a parede. Daniel disse que não conhecia, mas deixou eles ficarem lá e que não sabia que estavam vendendo drogas.

Em juízo o guarda municipal Mauro disse que atenderam um alarme disparado numa creche. Viram uma pessoa, que fugiu. Entrou num terreno, aparentemente uma residência. Foram atrás dele. Ele tinha dinheiro e ao lado do casal, junto ao colchão, os entorpecentes. Cocaína, pedra e maconha. O que tinha mais era pedra, 90, quase 100. Dos outros 23, 28. Tinha um senhor, jogado, na casa. Aparentemente embriagado. Na delegacia ele disse que morava lá. Não disse porque o casal estava lá. Deixou-os ficar ali. Eles estavam deitados em um colchão. Não se lembra se estavam com um lençol. Não sabe dizer se eram um casal ou amigos. Era difícil entender o que o dono dizia. Na delegacia falou que era dono. Não os conhecia antes.

Como se vê, não há a menor dúvida de que os réus praticaram o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando visualizaram o réu, que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e entrando em um imóvel abandonado, ensejando o acompanhamento.

Ingressaram no local e abordaram o réu, que estava em companhia da ré, em um dos cômodos.

Em vistoria, os guardas encontraram, no quarto em que foram abordados, dois pacotes, em cujo interior havia 25 microtubos contendo cocaína, 28 porções de maconha e 97 pedras de crack, bem como, em revista pessoal, acharam R\$ 59,00 em posse do réu, e R\$ 120,00 com a ré.

O réu negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Alegou ser somente usuário de crack e cocaína, sendo que estava em um imóvel abandonado, juntamente com outros usuários de droga, utilizando entorpecentes, e que com a chegada da Guarda Municipal, os indivíduos empreenderam fuga. Afirmou que a quantia apreendida consigo é oriunda de seu trabalho.

A ré também negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos no local. Afirmou ser usuária de drogas e que estava no imóvel abandonado, juntamente com outros usuários, utilizando drogas.

Todavia, apenas o casal estava no quarto em que se encontravam as drogas, escondidas entre a parede e o colchão sobre o qual estavam. Traficante algum deixaria expressiva quantidade de drogas abandonada em local sabidamente frequentado por usuários.

A tese da Defesa quanto à irregularidade da entrada dos policiais na residência do réu não deve prosperar.

Inicialmente, porque não se tratava de uma residência, mas de uma construção

abandonada, com livre acesso a quem quer que fosse.

Também porque os guardas foram atrás de indivíduo que, demonstrando nervosismo, ao perceber a aproximação dos guardas, empreendeu fuga em direção a esta construção. Não havia muro ou portão.

Com a fuga, havia fundada suspeita de que algo ilícito estaria sendo cometido.

Trata-se, no caso, de flagrante regular, já que o tráfico de entorpecentes constitui modalidade delituosa que se enquadra como crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo e, diante da situação flagrancial, a irregularidade se desfez.

Além disso, a tese defensiva de que os Guardas Municipais não poderiam ter efetuado a prisão dos réus não se sustenta.

Ao contrário, a Guarda Municipal tem o dever de agir, diante do crime que estava sendo cometido. Aliás, qualquer do povo está autorizado a prender aquele que está em flagrante delito (artigo 301 do CPP: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito").

Com mais razão a Guarda Municipal, a qual compete colaborar com os órgãos de segurança pública, de forma integrada, para a paz social (Lei 13.022/2014, artigo 5.º).

Nesse sentir, uma vez constatada determinada situação de flagrância – como foi o caso dos autos –, caso os agentes públicos deixassem de agir, estariam omitindo-se na prática de ato de ofício imposto pelo ordenamento jurídico, com implicações negativas ao resguardo da segurança pública.

No mesmo sentido também a orientação jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL.

VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notitia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. [....]" (STJ, HC 583610 / SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data de Publicação: DJe 14/08/2020).

No mais, os agentes de segurança pública apresentaram relatos firmes e coesos, sendo uníssonos em informar a dinâmica dos fatos e como acharam os entorpecentes e dinheiro com os réus.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de policiais.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

Sobre a questão, como já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (STF - Habeas Corpus nº 72.608-SP - Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Ora, os policiais não tinham por que incriminar os réus.

Portanto, a autoria delitiva é irrefutável.

O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo, e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Nestes autos, ficou claro que os réus tinham em depósito as drogas apreendidas, portanto, desnecessário terem sido flagrados em ato de venda.

Nesse sentido: "Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação" (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câ. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antonio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

E, ainda que sejam usuários de entorpecentes, o que não se duvida, isso não descaracteriza o crime.

"O traficante pode também ser viciado e, concomitantemente, guardar ou trazer consigo para uso próprio e para a disseminação do vício; por outro lado, o viciado também pode ser instrumento de difusão do mal, quando fornece a droga a outrem. Em ambas as hipóteses acima referidas, prevalecerá o delito mais grave, ficando absorvido o delito do artigo agora comentado. Tanto no caso de um traficante que traz consigo a droga para uso próprio como no caso de alguém que, trazendo originalmente para uso próprio, vem a desviar essa destinação fornecendo-a a outrem, o bem jurídico atingido é a saúde pública em sua forma substancialmente mais grave, não podendo o que dissemina o vício beneficiar-se arguindo sua condição de usuário da droga" ("Tóxicos Prevenção Repressão", Vicente Grecco Filho, Saraiva, 7ª edição p. 119).

Outrossim, é o entendimento dos tribunais:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

As circunstâncias evidenciam o intuito da mercancia.

A materialidade também está devidamente demonstrada, pois o laudo do exame químico-toxicológico analisou o material apreendido e constatou que se tratava de cocaína, em sua forma pura e petrificada, e Tetrahidrocannabinol (THC) (fls. 114/116).

Sobreleva notar que a quantidade de droga apreendida (10,26g de cocaína em sua forma pura - pó branco de granulometria fina, 11,2g de cocaína em sua forma petrificada - crack e 27,39g de maconha), a forma de acondicionamento (a cocaína distribuída em 25 microtubos, a maconha disposta em 28 porções individuais e o crack fracionado em 97 pedras), as circunstâncias em que ocorreram os fatos (guardas realizavam patrulhamento, quando observaram alguém empreendendo fuga ao visualizar a guarnição, em seguida passaram a realizar acompanhamento, constatando que ele adentrou em um imóvel abandonado, visando fugir da abordagem, até que encontraram os réus no local, em posse da considerável quantidade de drogas), a quantia encontrada em posse dos réus (R\$ 179,80), evidenciam de forma clara o intuito da mercancia.

Há impedimento para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, porquanto os réus são reincidentes, demonstrando a habitualidade criminosa.

Outrossim, inviável a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei

11.343/2006, conforme pretende a Defesa, uma vez que as circunstâncias de mercancia se mostraram bem delineadas, e o fato de não serem os réus flagrados em ato de comércio não impede a configuração do tráfico de entorpecentes, já que o simples "trazer consigo" é suficiente para a subsunção típica.

Devem, portanto, os acusados responderem pelo delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a acusada não ostenta antecedentes desabonadores (fls. 57/59 e 170/171), já que única condenação transitada em julgado será considerada na segunda fase da dosimetria, bem como noto que o réu possui maus antecedentes (processo n.º 135/2001 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 01, às fls. 52, cujo trânsito em julgado se deu em 25/07/2002; processo n.º 981/99 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 02, às fls. 52/53, cujo trânsito em julgado se deu em 19/12/2001; processo n.º 1404/1999 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 04, às fls. 53, cujo trânsito em julgado se deu em 28/02/2002; e processo n.º 44/01 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 05, às fls. 54, cujo trânsito em julgado se deu em 23/02/2004). Deve-se, ainda, ser sopesada, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza, variedade e a quantidade das substâncias, a personalidade e a conduta social do agente. Portanto, é de se considerar a variedade de droga apreendida (cocaína, crack e maconha), o que aumenta a culpabilidade e as consequências do delito, indicando que os réus estão mais inserido no mundo do crime, lidando com diversos tipos de drogas e alcançando um número maior de usuários, evidenciando sua maior dedicação em comerciar entorpecentes, em detrimento da saúde de terceiros, bem como a natureza deletéria de uma das drogas, apreendidas, cocaína em forma de crack, que gera intensa e rápida dependência, acarretando condutas extremamente violentas nos casos de abstinência e que acaba empurrando os usuários a outros crimes violentos, a fim de obterem dinheiro para comprarem mais e mais drogas, o que aumenta a culpabilidade do agente e as consequências dos delitos. Por fim, deve ser considerado que ambos os réus cumpriam pena quando foram presos. A ré estava solta em razão do livramento condicional concedido em 17/07/2018, conforme informação do processo de execução criminal n.º 0001947-91.2017.8.26.0520, às fls. 170, todavia, o término de sua pena estava previsto para 19/12/2021, conforme informações de fls. 254/255. Já o réu cumpria pena em regime aberto desde 27/08/2018, conforme informações complementares de fls. 51, execução criminal n.º 512.651. Estes fatos demonstram que a conduta social dos réus é mais reprovável, pois evidencia o caráter desvirtuado deles, um verdadeiro comportamento social inadequado, descomprometido com o cumprimento da ordem e da lei, evidenciando que não estão preparados para o retorno ao convívio social. Com relação ao réu, de acordo com o artigo 36 do Código Penal, o regime aberto se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, ausentes a ele. Desta forma, fixo a pena-base do réu em 1/3 acima do mínimo legal, para que fique em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, bem como fixo a pena-base da ré em 1/4 acima do mínimo legal, para que fique em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A valoração negativa da conduta social dos réus se encontra em plena consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVA LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC n.º 556.444/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/08/2020).

A exasperação da pena-base se mostra necessária em razão da natureza deletéria de

uma das drogas traficadas, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1. Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 2. Trata-se o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de norma de direito material de observância obrigatória quando da fixação da pena nos delitos por ela regulados por imperativo constitucional, eis que beneficia o agente dada a possibilidade de redução da reprimenda. 3. Faz jus à diminuição da pena o paciente que preenche todos os seus requisitos, não sendo motivação idônea para se afastar a incidência da minorante a menção no sentido de ser o paciente detentor de maus antecedentes levando-se em conta condenação ainda não transitada em julgado. 4. Habeas corpus denegado, e concedida a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena do paciente na ação penal de que aqui se cuida a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa” (STJ, HC 152.285/SP, Ministro Relator Haroldo Rodrigues, j. em 23/02/2010 - destaquei).

O mesmo entendimento é compartilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“A reprimenda mostrou-se adequada e motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 126 tráfico) e pela potencialidade lesiva da droga, acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 125 roubo circunstanciado), alcançando a pena final de 07 anos de reclusão; não aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante da reincidência. Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como estabelecida” (14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0004327-68.2012.8.26.0292. Relator Des. Marco de Lorenzi. J. em 04/07/2013 - destaquei).

Tratando-se de réus reincidentes (Milena: processo n.º 0007152-14.2016.8.26.0625 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 170, cujo trânsito em julgado se deu em 30/04/2019; Luiz: processo n.º 0020372-21.2012.8.26.0625 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 06, às fls. 54 e 174, cujo trânsito em julgado se deu em 02/07/2014; e que ambos cumpriam pena por estas condenações quando cometeram o crime), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitativa, agravo a pena deles em 1/5, para que passe a ser de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa para o réu Luiz, e em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para a ré Milena.

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

À míngua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

Deverão os réus iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal, pois é de se considerar que são reincidentes, bem como a variedade das drogas apreendidas e a natureza deletéria de uma delas, conforme já valorado na primeira fase da dosimetria da pena.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica dos réus a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, na forma do

artigo 29, caput, do Código Penal, os réus:

(I) LUIZ FABIANO DA SILVA, filho de José Florêncio da Silva e Benedita Márcia dos Santos Silva, RG n.º 42.253.339, nascido aos 27 de julho de 1981, natural de Taubaté/SP, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo; e

(II) MILENA APARECIDA DE SOUZA, filha de Antônio Celso de Souza e Maria José de Macedo Souza, RG n.º 42.433.569, nascida aos 13 de novembro de 1981, natural de Taubaté/SP, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Apelo em liberdade.

Condeno os réus a arcarem, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois são representados pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e no artigo 62 da Lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder dos réus (depósito judicial às fls. 113), porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Encaminhem-se, imediatamente, certidão de objeto e pé atualizada para a 1ª e 2ª Vara das Execuções Criminais, para que instruam os autos dos processos n.º 512.651 (Réu Luiz - 1ª VEC) e 0001947-91.2017.8.26.0520 (Ré Milena - 2ª VEC), tendo em vista que eles cumpriam pena quando cometeram o crime.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda.

P.R.I.C. Oportunamente ao arquivo. Taubaté, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA